

1501536-88.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... de drogas ou reconhecimento do tráfico privilegiado. É o relatório. Fundamento e decido. Procede a pretensão punitiva estatal. Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes é incontroversa e está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e, principalmente, laudo de exame químico-toxicológico, que resultou positivo para a substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

3ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-140 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1501536-88.2021.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 830/21/911 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE GABRIEL FERNANDES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 08 de março de 2022, às 14:00h, foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, através da ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. FELIPE CAVASSO, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento em que figura como réu ALEXANDRE GABRIEL FERNANDES. Presente na sala virtual a Promotora de Justiça, Drª Neiva Paula Paccola Carnielli Pereira. Presente na sala virtual o réu ALEXANDRE GABRIEL FERNANDES. Presente na sala virtual o seu defensor, o Drº Hiêridy Buono de Souza - OAB 354558/SP. A seguir, foram ouvidas por videoconferência, duas testemunhas de acusação e interrogado o réu, através da ferramenta Microsoft Teams. Pela defesa foi dito que desistia da inquirição das testemunhas arroladas, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Como não houvesse mais prova a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução. Pelas partes foi dito que não tinham requerimentos de diligências. Não havendo mais provas a produzir o MM. Juiz deu por encerrada a instrução e determinou a imediata realização dos debates orais, através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Alexandre Gabriel Fernandes como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 27 de abril de 2021, por volta de 09h58min, na Avenida Pacaembu, 380, Jd. Das Rosas, nesta cidade e comarca, ele trazia consigo, para fins

de venda e comercialização, 13 (treze) porções de maconha, drogas acondicionadas de forma a pronta entrega a consumo de terceiros, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17, fotos de fls. 26 a 30 laudo de constatação de fls. 21/22 e laudo químico de fls. 72 a 74, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O denunciado ainda portava um celular (fls. 16, com foto as fls. 31). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O denunciado foi notificado e apresentou defesa prévia. Foi-lhe concedida liberdade provisória (fls. 131/132). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, a desclassificação para o crime de porte de drogas ou reconhecimento do tráfico privilegiado. É o relatório. Fundamento e decido. Procede a pretensão punitiva estatal. Com efeito, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes é incontroversa e está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e, principalmente, laudo de exame químico-toxicológico, que resultou positivo para a substância Tetrahidrocannabinidiol (fls. 72/74). A autoria também é certa. Os policiais militares ouvidos nesta data, de forma uníssona, confirmaram a apreensão do réu na posse das porções de maconha e admissão por parte dele, na ocasião da prisão, de que realmente estava traficando no local, ponto conhecido como de venda de entorpecentes. Os policiais relataram qual droga foi apreendida e em que circunstância isso se deu, além da denúncia anterior de que um indivíduo, com as mesmas características do réu, estava comercializando drogas naquele lugar, confirmando-se os fatos contidos na denúncia. É certo que, em juízo, o acusado se retratou da confissão havida na fase policial. Mas é preciso considerar que, além de ele ter fornecido detalhes de como ocorria a venda à época dos fatos, ambos os agentes públicos que o apreenderam foram coesos ao confirmar que ele admitiu a realização do comércio ilícito. Ademais, a condição de usuário não exclui a possibilidade da prática do tráfico de drogas. Sobre o depoimento dos policiais militares, é certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença. O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental. No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado, pois este próprio alegou que conhecia os milicianos. Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações. Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP). De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Acerca da quantidade da substância entorpecente para fins de consumo pessoal, confira-se o seguinte posicionamento doutrinário: Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha

há 0,33 gramas da citada substância entorpecente. (Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio. Legislação Penal Especial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 114). Nessa medida, com o réu foram apreendidas treze porções individualizadas de maconha, acondicionadas de forma usual para entrega a terceiros, atividade que foi admitida pelo acusado na fase inquisitiva. Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena. Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), observo que o réu é primário e não ostenta Maus antecedentes, motivo pelo qual nada há que recomende exasperação. Fixa-se a pena-base no patamar legal mínimo, correspondente a cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes que permitam a fixação da pena no patamar legal mínimo, de acordo com a súmula 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, ainda que consideradas a confissão espontânea e a menoridade relativa, descabe a diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, reconhece-se a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu é primário, não ostenta Maus antecedentes, não está comprovado que se dedicava à atividade criminosa, tampouco que integrava organização criminosa, razão pela qual, sendo favoráveis circunstâncias judiciais, diminui-se a pena de dois terços, chegando-se a um ano e oito meses de reclusão e pagamento cento e sessenta e seis dias-multa. O regime de cumprimento da pena será o aberto porque, nos termos do recente entendimento adotado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 118-533/MS, não se aplicam ao tráfico minorado as regras particulares destinadas aos crimes hediondos, o que impõe tratamento benéfico e diferenciado ao indivíduo que comete este crime de forma episódica. O voto-vista proferido pelo eminente ministro Edson Fachin explicitou que na hipótese de aplicação da minorante em grau máximo, como bem registrado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, a pena mínima possível equivale a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Referida reprimenda sequer ultrapassa o patamar estabelecido como marco definidor de infrações de menor potencial ofensivo, caracterizadas por pena máxima não superior a 02 (dois) anos (art. 61, Lei 9.099/95). Da mesma forma, essa pena não impediria a substituição (art. 44, CP), e, salvo motivação idônea (Súmulas 718 e 719/STF), recomendaria a fixação de regime inicial aberto. Além disso, sob a ótica da pena mínima cominada, se aplicável o procedimento comum previsto no CPP, não se exigiria rito processual de maior robustez (art. 394, CPP). Ademais, a pena mínima não preenche o pressuposto autorizador da prisão preventiva previsto no art. 313, I, CPP. Na fase da execução, o tempo mínimo de pena não configuraria óbice à suspensão condicional (art. 156, LEP) ou ao livramento condicional (art. 83, CP). Não bastasse, cumpre assinalar que o crime de associação para o tráfico, que reclama liame subjetivo estável e habitual direcionado à consecução da traficância, não é equiparado a hediondo. Ou seja, afirmar que o tráfico minorado é hediondo significaria que a lei ordinária conferiria ao traficante ocasional tratamento penal mais severo que o dispensado ao agente que se associa de forma estável para exercer a traficância de modo habitual, a escancarar que tal inferência consubstanciaria violação aos limites que regem a edição legislativa penal. É óbvio que não se

cuida de atribuir ao tráfico minorado o caráter de infração de menor potencial ofensivo, ou de afirmar que o tempo de pena confere, ipso facto, direito subjetivo aos benefícios listados. Trata-se, tão somente, de, sob o prisma da quantidade mínima de pena, signo a traduzir, por excelência, a gravidade do crime e a extensão da necessidade de punição penal, extrair que o tratamento equiparado a hediondo configuraria flagrante desproporcionalidade. Isso porque, sob todos os ângulos elencados, o ordenamento jurídico confere ao delito de tráfico minorado, segundo a perspectiva da quantidade de pena, tratamento que não se coaduna com a agressividade ínsita à hediondez por equiparação. Considerando que a intensidade do tratamento penal deve guardar uniformidade por parte do legislador, à luz das demais respostas penais e institutos processuais, depreendo que a equiparação a crime hediondo não alcança o delito de tráfico na hipótese de incidência da causa de diminuição em exame. Ao contrário, visto que tal consequência jurídica se amolda

ao espírito da causa de diminuição, destinada a conferir tratamento penal diferenciado ao agente episódico consistente em rigor arrefecido que destoa das características inspiradoras dos delitos hediondos e equiparados. É nessa linha que, no caso do tráfico de drogas, o encarceramento não é uma opção legislativa marcante na hipótese de agentes episódicos, âmbito normativo que não pode ser desprezado no momento de concretização do programa da norma. Com efeito, não observaria a Constituição e a unidade do sistema jurídico a norma que atribuísse hediondez dissociada das demais nuances da infração penal, as quais, repita-se, derivam das demais decisões políticas do próprio legislador. Nesse contexto, a partir de um juízo conglobante, compreendo que não se verifica hipótese de hediondez equiparada. Diante da expressividade da minorante, bem como que se trata de norma excepcional e que, portanto, desafia interpretação restritiva, e na linha do bem lançado voto do eminente Ministro Gilmar Mendes, compreendo que o legislador não desejou incluir o tráfico minorado no regime dos crimes equiparados a hediondos, tampouco nas hipóteses mais severas de concessão de livramento condicional, caso contrário, o teria feito de forma expressa e precisa. Além disso, a avaliação sistemática, sob o prisma da proporcionalidade, reforça essa conclusão. Ainda, presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Ante o exposto, condeno ALEXANDRE GABRIEL FERNANDES, qualificado nos autos, à pena de um ano e oito meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no patamar legal mínimo, como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que deverá ser fixada no juízo das execuções, e pagamento de prestação pecuniária, no valor um salário mínimo, a ser revertida a instituição de caridade oportunamente indicada. Nada obsta o recurso em liberdade. Fica autorizada a restituição do celular apreendido ao acusado, porque não há interesse para fins de investigação. Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida. O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvada a gratuidade que ora lhe defiro. Com o trânsito em julgado: a) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; b) Lance-se a condenação no sistema informatizado oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); c) proceda-se a atualização do valor da multa e, após manifestação das partes, intime-se o réu para pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de execução; d) oficie-se à delegacia de polícia local, solicitando a incineração das amostras das substâncias entorpecentes, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. As partes saíram intimadas da sentença neste ato. O réu saiu intimado da sentença condenatória neste ato. Eu, Carlos André Garbuglio, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA